

1504591-57.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Elaine Cristina Pulcineli Vieira Gonçalves

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 15ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/05/2022

... ainda pela desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para o crime de uso no que toca ao réu Anderson.

A Defesa dos acusados Elaine e Henrique, por sua vez, requereu a absolvição dos acusados, por insuficiência probatória para a condenação. Subsidiariamente, buscou a desclassificação da conduta tipificada como crime de tráfico de drogas prevista no artigo 33 da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

15ª Vara Criminal

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1504591-57.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1504591-57.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDERSON DA ROCHA TEIXEIRA e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Elaine Cristina Pulcineli Vieira Gonçalves

Vistos.

ELAINE DE OLIVEIRA NANTES, HENRIQUE AMORIM OLIVEIRA e ANDERSON DA ROCHA TEIXEIRA, todos devidamente qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, porque, no dia 23 de fevereiro de 2022, por volta das 17h00min, na Rua Guaianazes, 73, Santa Cecília, nesta cidade e comarca da capital, previamente ajustados e com unidade de desígnios e propósitos, vendiam e traziam consigo, drogas, em desacordo com determinação legal e regulamentar, consistentes em de 21 (vinte e uma) porções de maconha, totalizando o peso líquido de 37.7g (trinta e sete gramas e sete decigramas), substância entorpecente que causa dependência física e psíquica.

Recebida a denúncia os réus foram citados, notificados e apresentaram resposta à acusação.

Após a manutenção do recebimento da denúncia, em sede de audiência de instrução, debates e julgamento foram ouvidos dois policiais e os réus foram interrogados.

Encerrada a instrução criminal, o Ministério Público pleiteou pela condenação dos acusados Elaine e Henrique nos exatos termos da denúncia e ainda pela desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para o crime de uso no que toca ao réu Anderson.

A Defesa dos acusados Elaine e Henrique, por sua vez, requereu a absolvição dos

acusados, por insuficiência probatória para a condenação. Subsidiariamente, buscou a desclassificação da conduta tipificada como crime de tráfico de drogas prevista no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 para o crime de porte de drogas para uso pessoal, previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, o afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "j", do CP e em caso de eventual condenação pelo crime de tráfico pugnou pela fixação da pena base no mínimo legal, reconhecendo a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33 parágrafo 4º da Lei nº 11.343/06, com fixação de regime inicial aberto com substituição de pena privativa de liberdade em restritiva de direito, e conferindo o direito de responder em liberdade.

Já a Defesa do réu Anderson pugnou pela absolvição do acusado por insuficiência probatória para a condenação, ou em caso de condenação a desclassificação do crime de tráfico para o crime de uso de entorpecentes, o afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal e remotamente não sendo este o entendimento requereu a fixação da pena base no mínimo legal, reconhecendo a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33 parágrafo 4º da Lei nº 11.343/06, com fixação de regime inicial aberto com substituição de pena privativa de liberdade em restritiva de direito, e conferindo o direito de responder em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

De fato, a ação contra os acusados deve ser julgada parcialmente procedente. Com efeito, os dois policiais ouvidos em juízo, foram uníssomos em afirmar que estavam em patrulhamento de rotina pela região central desta Capital, em local já conhecido como sendo ponto de tráfico de entorpecentes e viram a ré Elaine entregando uma sacola verde para dois homens e em razão dessa atitude resolveram abordá-los. Assim que a polícia se aproximou todos tentaram fugir, mas os três foram capturados.

Os policiais relataram, ainda, que a sacola foi encontrada na posse do acusado Henrique e dentro dela foram localizadas 10 porções de maconha. Em revista pessoal, com o acusado, em um dos bolsos de sua vestimenta, ainda havia mais 04 porções da mesma droga e que com o outro rapaz, que fora visto ao seu lado, no momento em que a ré lhe entregou a sacola, foram encontradas outras 06 porções de maconha e uma quantia em dinheiro. A mulher também foi revistada e com ela ainda havia 01 porção de entorpecente.

Afirmaram ainda, que Elaine foi indagada a respeito da sacola e disse que Henrique havia pedido para ela guardar a sacola por alguns instantes e depois para lhe devolver o que foi feito.

Ao serem ouvidos em juízo os réus negaram a prática do crime e afirmaram que estavam no local apenas para fazer uso de entorpecentes e que as drogas com eles encontradas não se destinavam a venda de terceiros.

A ré Elaine disse que foi abordada por policiais na região Central e que trazia consigo apenas uma única porção de maconha que havia adquirido para usar. Negou ter entregue a sacola com as drogas a um dos rapazes, afirmando que não os conhecia. Anderson, por sua vez, disse que é usuário de drogas e que foi preso com algumas porções que foram adquiridas para seu uso próprio e que apenas já tinha visto os outros dois réus anteriormente, mas não os conhecia.

Henrique também negou que tivesse recebido a sacola das mãos de Elaine e disse que estava no local apenas para comprar as drogas para seu uso próprio.

Estas são as provas colhidas e diante delas, não obstante as alegações da combativa Defensora Pública, que atua nesse juízo, sem dúvida que a absolvição dos acusados Elaine e Henrique em face das provas colhidas é absolutamente descabida.

A materialidade do delito em questão restou comprovada pelo boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, laudo pericial de fls. 236/238, com resultado POSITIVO para entorpecentes.

A autoria também é inconteste.

A própria ré Elaine, ao ser ouvida em sede policial confirmou a versão apresentada pelos policiais em todas as oportunidades em que foram ouvidos, e, e em juízo, não soube esclarecer seu interrogatório de fls. 29, dizendo apenas que nada entregou para Henrique.

Já Henrique disse que a fls. 33, que estava no local e viu Elaine entregando a sacola para "outro cara", e também não soube esclarecer porque os policiais disseram que a sacola estava em seu poder.

Ora, diante das provas colhidas, não há dúvidas de que as drogas encontradas com o réu Henrique, foram as mesmas que lhes foram repassadas pela corré Elaine, e que se destinavam a venda a terceiros.

Afasta-se portanto, a desclassificação do crime de trafico para o crime de uso como requerido pela Defesa.

No mais, de asseverar, ainda, que o simples fato de as testemunhas ouvidas serem policiais nada significa para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que estes sejam recebidos com reservas, mesmo que não tenham sido arroladas outras testemunhas.

Neste compasso, imprescindível salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que os depoimentos de policiais, apenas pela sua condição, não podem ser desconsiderados ou desacreditados, em primeiro lugar porque, constitucionalmente, são os policiais aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei. De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública o direito (e o dever) de prestar contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento.

A desconsideração de depoimento de policial somente procede quando decorre de atos de parcialidade, motivados por vingança ou perseguição e desde que comprovados de forma segura e objetiva, o que efetivamente não veio a ser comprovado nestes autos. Confira-se: "Prova - Testemunhal - Depoimento prestado por policiais participantes da diligência - Validade - Ausência de interesse em incriminar o réu - Recurso não provido. Os funcionários da Polícia merecem, em seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresenta razão, concreta de suspeição" (Relator: Silva Pinto, Apelação Criminal n. 153.983-3, Santos, 7.7.94).

Por outro lado as circunstâncias em que os réus foram presos, não deixam duvidas de que ambos estavam no local fazendo a venda dos entorpecentes.

Neste sentido: "PROVA CRIMINAL - Tóxico - Tráfico - Quantidade da droga apreendida, aliada a outras circunstâncias, que induzem à certeza de destinação ao comércio - Recurso não provido". (Relator: Lustosa Goulart - Apelação Criminal n.º 159.552-3 - São Paulo - 05.05.94).

Dessa forma, considerando-se que os réus não produziram prova alguma capaz de infirmar os fatos que lhe são atribuídos na denúncia merece total acolhimento a pretensão punitiva e uma vez que as condutas dos réus subsumem-se ao tipo penal descrito no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, é de rigor a condenação.

Já no que toca ao corréu Anderson porém outra sorte lhe convém, isso porque o que temos de concreto, é o simples fato de ele estar próximo do corréu Henrique no momento em que o corréu recebeu a sacola contendo as drogas, e ainda o fato de que com ele foram encontradas somente 06 porções de droga, conforme se depreende dos depoimentos dos dois policiais em todas as oportunidades em que foram ouvidos.

Pois bem, diante disso, como não há nos autos provas de que o réu Anderson recebeu as drogas que estavam dentro da sacola, e ainda considerando que o réu disse que de fato estava portando as drogas que acabara de comprar para uso próprio, não há como enquadrá-lo também na figura prevista no art. 33, da Lei de drogas, sendo portanto, a desclassificação do delito para o crime de porte de entorpecentes para uso a medida que se impõe.

Caracterizadas as infrações penais passo a individualizar a pena a ser aplicada a cada acusado.

Da ré Elaine:

Trata-se de ré é primária sem antecedentes criminais atestados, conforme certidão atualizada juntada nos autos. (fls. 61/62).

Assim, é o caso de se aplicar a pena base fixada em seu mínimo legal, consistente em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, deve-se considerar que o crime foi cometido durante a vigência de estado de calamidade pública decorrente da pandemia do COVID-19, reconhecida por meio do Decreto nº 64.879/2020 de 20/03/2020.

Veja-se que na época dos fatos, sequer o Carnaval uma festa nacional e de grande repercussão econômica e cultural não pode ser realizada justamente com o intuito de frear o avanço da nova variante a ômicron, que estava causando a morte de inúmeras pessoas.

Neste ponto, em que pese as alegações da defesa, e decisões afastando a referida agravante, ressalta-se que para esta magistrada, o estado de calamidade pública acabou por facilitar a execução de crimes, ainda mais diante da necessidade de isolamento social a fim de retardar a propagação da doença, o que gerou a redução de pessoas e policiais nas ruas, defasando a vigilância estatal.

Neste sentido:

"Na segunda fase, o crime foi praticado durante o período de calamidade pública causada pela pandemia do COVID-19, nos termos do Decreto Estadual nº 64.879/20. Justifica-se a aplicação da agravante mencionada, uma vez que o cometimento do crime nessas circunstâncias de calamidades públicas demonstra insensibilidade moral do agente para com a solidariedade social, visto que o período impõe o dever social de recíproca assistência. Ademais, é um período em que há maiores dificuldades de policiamento, por exemplo, e o agente aproveita-se disso para a prática de delitos" (TJ-SP - PR: 15078616020208260228 SP 1507861- 60.2020.8.26.0228, Relator: Tetsuzo Namba, Data de Julgamento: 21/07/2020, 11ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 21/07/2020).

E ainda: "(...) Por outro lado, cabível a manutenção da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea j, do CP. Ora, o acusado praticou o presente crime durante período de calamidade pública (pandemia), instituído pelo Decreto Legislativo nº 6, do Congresso Nacional, e Decreto nº 64.879, do Estado de São Paulo, ambos em vigor na data em que perpetrado o delito em apreço, não podendo prosperar a alegação de suposto desconhecimento, mormente porque decretadas diversas restrições a toda população, para fins de contenção da doença. De se sublinhar, outrossim, que se trata de agravante de caráter objetivo, não se exigindo, portanto, requisito outro adicional que não a mera existência do estado emergencial, a atribuir maior grau de reprovabilidade às condutas ilícitas perpetradas durante sua vigência" (Apelação Criminal 1509419- 67.2020.8.26.0228. Rel. Edison Brandão. Quarta Câmara de Direito Criminal TJSP. J. 26/01/2021).

"Não há que se falar em afastamento da agravante relativa ao cometimento do crime durante estado de calamidade pública. Isso porque trata-se de circunstância de caráter objetivo, bastando que o crime ocorra durante aquele estado emergencial, não havendo exigência legal da presença de outros requisitos para a sua configuração. Com efeito, é de notório conhecimento o reconhecimento do estado de calamidade pública decorrente da pandemia do COVID-19 até 31 de dezembro de 2020, conforme Decreto Legislativo nº 06, de 20 de março de 2020. Assim, qualquer indivíduo que cometa crimes no período compreendido no citado decreto, como no caso em comento, terá sua pena agravada, haja vista que o agente se vale de uma situação dramática pela qual passa o país para delinquir. Irrelevante, ainda, que não seja o criminoso o provocador da situação excepcional; o que prevalece é sua atitude de se valer das facilidades que dela decorrem, in casu, o isolamento social, com diminuição do policiamento, por exemplo. Sobreleva registrar, outrossim, que as calamidades públicas impõem o dever social de mútua assistência, e o cometimento de crime nessas circunstâncias demonstra insensibilidade para com os mandamentos emanados da solidariedade social. A calamidade produz situação de incapacidade, total ou parcial, de defesa por parte da sociedade, e a exigência de abstenção da conduta é maior do que no caso de não concorrerem tais circunstâncias." (TJSP, Apelação Criminal nº 1512914-22.2020.8.26.0228, Rel. Des. Camilo Léllis, 4ª Câmara Criminal, j. 09/0).

A 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo: Autos nº 1509419-67.2020 - "O acusado praticou o presente crime durante período de calamidade pública (pandemia), instituído pelo Decreto Legislativo nº 6, do Congresso Nacional, e Decreto nº 64.879, do Estado de São Paulo, ambos em vigor na data em que perpetrado o delito em apreço, não podendo prosperar a alegação de suposto desconhecimento mormente porque decretadas diversas restrições a toda população, para fins de contenção da doença", escreveu o magistrado em seu voto.

"De se sublinhar, outrossim, que se trata de agravante de caráter objetivo, não se exigindo, portanto, requisito outro adicional que não a mera existência do estado emergencial, a atribuir maior grau de reprovabilidade às condutas ilícitas perpetradas durante sua vigência."

"O Decreto Legislativo nº 06/2020, do Congresso Nacional, e o Decreto Estadual nº 64.879/2020, reconheceram a situação de calamidade pública resultante da pandemia concernente ao novo coronavírus. E o reconhecimento de tal circunstância motiva a incidência de referida agravante.

Ora, diante de tal situação de calamidade pública, a população foi orientada e, em algumas cidades, forçada, a fechar-se em casa. Vários estabelecimentos comerciais foram obrigados a cerrar portas. Esforços financeiros e humanos foram dirigidos pelo Estado ao combate à pandemia.

Desse modo, toda a sociedade foi atingida e sofreu as consequências de referida pandemia, a qual foi reconhecida como calamidade. É indiscutível que o cometimento de qualquer crime durante tal circunstância encontra maior facilidade e superior reprovabilidade, fazendo jus à respectiva exacerbação da reprimenda.

Pese tenha inteligência no sentido de emprestar uma interpretação mais restritiva para a norma prevista no artigo 61, inciso II, "j", do Código Penal, a Câmara assentou entendimento pela incidência da circunstância agravante numa situação como a dos autos.

A compreensão é de, com o estado de calamidade provocado pela ação do coronavírus (declarado pelo Decreto Legislativo 06/2020, do Congresso Nacional), "a população foi orientada e, em algumas cidades, forçada a ficar em casa. Vários estabelecimentos comerciais foram obrigados a fechar. Esforços financeiros e humanos foram dirigidos pelo Estado ao combate da pandemia.

Desse modo toda a sociedade foi atingida e sofreu as consequências de referida pandemia, a qual foi reconhecida como calamidade. É indiscutível que o cometimento de qualquer crime durante tal circunstância encontra maior facilidade e superior reprovabilidade, fazendo jus à respectiva exacerbação da reprimenda" (Apelação nº 1512223-08.2020.8.26.0228, rel. Des. Hermann Herschander). Não se exige na linha do que penso - que o agente se aproveite especificamente do quadro de pandemia para a realização do crime, ou seja, que essa situação tenha facilitado, de alguma maneira, a ação criminosa. É suficiente, para a incidência da circunstância agravante, que o crime tenha sido cometido durante o período de calamidade pública critério temporal puramente objetivo. Orientação que acompanho nesta oportunidade, em atenção ao princípio da colegialidade (STF, Ag. Reg no RHC nº 142.585, rel. Min. Celso de Mello).

Desse modo, a pena deve ser agravada em 1/6, chegando-se a 5 anos, 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Não há atenuantes a se considerar.

Na terceira fase, não há causas de aumento de pena para serem levadas em conta.

Por outro lado, não obstante a argumentação do combativo membro do Ministério Público que atua neste juízo, não há prova de que a acusada pertença à organização criminosa, nem tampouco de que se dedique a atividades criminosas, já que os processos mencionados pelo "parquet" encontram-se ainda em andamento e não foram concluídos, não podendo portanto serem considerados como provas a impedir a aplicação do benefício legal.

No mais, considerando a quantidade de drogas apreendida, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, a pena deve ser reduzida no patamar máximo, chegando-se a 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 194 dias-multa, já que a lei apenas menciona que a diminuição será de 1/6 a 2/3, sendo a quantidade de drogas para esta magistrada um vetor a basilar tal redução.

Do réu Henrique:

O réu é primário e sem antecedentes criminais atestados, conforme certidão atualizada juntada nos autos. (fls. 60).

Assim, é o caso de se aplicar a pena base fixada em seu mínimo legal, consistente em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, deve-se considerar que o crime foi cometido durante a vigência de estado de calamidade pública decorrente da pandemia do COVID-19, reconhecida por

meio do Decreto nº 64.879/2020 de 20/03/2020, pelos motivos e fundamentos exaustivamente acima apontados, devendo a pena ser então agravada em 1/6, chegando-se a 5 anos, 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Não há atenuantes a se considerar.

Na terceira fase, não há causas de aumento de pena para serem levadas em conta.

Por outro lado, assim como acima ponderado, não há prova de que o acusado pertença à organização criminosa, nem tampouco de que se dedique a atividades criminosas, já que o processo mencionado pelo "parquet" ainda não foi concluído, não podendo, portanto ser utilizado para impedir a benesse prevista na lei de traficos.

No mais, considerando a quantidade de drogas apreendida, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, a pena deve ser reduzida no patamar máximo, pelos fundamentos expostos e ser fixada também ao corréu em 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 194 dias-multa.

Ausentes provas da condição econômica dos réus fixa-se o dia-multa no mínimo legal estabelecido.

Do réu Anderson:

Considerando a desclassificação do crime de trafico para o crime de uso de entorpecentes, nos termos do que dispõe a art. 28, inciso III, da Lei 11.343/06, condeno o acusado à pena de 01 mês de prestação de serviços à comunidade, considerando, sobretudo sua primariedade.

Diante do exposto julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO PENAL e o faço para condenar o réu Anderson como incurso nas penas do art. 28 da lei 11.343/06, à pena de 01 mês de prestação de serviços à comunidade. (art. 28, III) e para condenar os corréus Elaine e Henrique, à pena de 01 ano e 11 meses e 10 dias de reclusão e ao pagamento de 194 dias-multa, calculados na base do valor unitário mínimo, por estarem incursos no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006.

Em face das decisões reiteradas das cortes superiores, e, sobretudo, pelo fato de que os acusados são é primários e que o crime por eles cometidos não foi praticado com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, e ainda considerando o disposto no artigo 33, parágrafo 2º, do Código Penal, fixo o regime inicial aberto.

Nos termos do disposto no art. 44 do Código penal, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, que fica ora estabelecida por uma pena de prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo tempo da pena substituída e que deverá ser determinada no Juízo da Execução.

Em caso de eventual descumprimento, o regime inicial de cumprimento de pena é o aberto.

Nos termos do disposto no art. 77, inciso III, do Código Penal, deixo de aplicar o réu o "sursis".

Considerando o montante e a espécie de pena aplicada aos acusados, expeça-se alvará de soltura clausulado com urgência.

Transitado em julgado, expeça-se guia de execução definitiva.

Comunique-se o IIRGD e o TRE.

Oficie-se para a destruição integral da droga apreendida, inclusive eventual amostra para contraprova.

Custas na forma da lei.

Devendo ser ressalvado o previsto no art. 98, §3º do Código de Processo Civil, que expressamente revogou o art. 12 da Lei 1.060/50, no que toca aos réus representados pela Defensoria Pública do Estado.

P.R.I.C.

São Paulo, 10 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA